

1524334-87.2021.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Falsificação / Corrupção / Adulteração / Alteração de produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais

Magistrado: Paulo Fernando Deroma De Mello

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 16ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 02/02/2022

... das penas previstas para o crime de tráfico de drogas, contudo ainda prevalece nesta Turma a compreensão de inaplicabilidade das causas de aumento e redução de pena do tráfico ao delito do art. 273, § 1º-B do CP. 3. Mesmo admitindo-se a minorante, então incidiriam também as majorantes, a crime que tem pena do tipo básico até maior, tendo em vista que o preceito secundário ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

16ª Vara Criminal

Av. Dr. Abrahão Ribeiro, nº 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

1524334-87.2021.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1524334-87.2021.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Falsificação / Corrupção / Adulteração / Alteração de produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2275398/2021 - 01º D.P. SE, 20721952 - 01º D.P. SE, 2275398 - 01º D.P. SE

Autor:

Justiça Pública

Réu:

STHERLINE RICHARD

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Paulo Fernando Deroma De Mello

Vistos.

Stherline Richard apresentou embargos de declaração, sustentando omissão contida na sentença de fls. 317/324 (fls. 331/354). Aduz a Defesa omissão em razão da não aplicação do princípio da proporcionalidade e da ofensividade.

O Ministério Público manifestou-se contrariamente ao requerido.

Eis, em síntese, o relatório. Decido.

Conheço dos embargos e dou-lhes parcial provimento, uma vez que houve a referida omissão.

Nada obstante as alegações defensivas, o entendimento do E. Supremo Tribunal Federal versa sobre a situação específica de importação de medicamento sem registro no órgão de vigilância sanitária, o que não é o caso dos autos. O que inviabiliza a aplicação do preceito secundário do art. 273, caput, na redação original do Código

Penal, que previa pena de 1 a 3 anos de reclusão e multa. Segundo entendimento firmado pelo STF:

É inconstitucional a aplicação do preceito secundário do art. 273 do Código Penal à hipótese prevista no seu § 1º-B, I, que versa sobre a importação de medicamento sem registro no órgão de vigilância sanitária. Para esta situação específica, fica reprimido o preceito secundário do art. 273, na sua redação originária. (RE 979962, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 24/03/2021, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-113 DIVULG 11-06-2021 PUBLIC 14-06-2021) (grifei)

Nada obstante, para o Superior Tribunal de Justiça, o preceito secundário do artigo 273, § 1º-B do Código Penal, é inconstitucional, pois violaria o princípio da proporcionalidade. De modo que autorizou a aplicação analógica das penas previstas para o crime de tráfico de drogas. Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DESCAMINHO E EXPOR À VENDA E TER EM DEPÓSITO PARA A VENDA DE PRODUTO SEM REGISTRO, QUANDO EXIGÍVEL, NO ÓRGÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA. CIGARROS DE PROCEDÊNCIA ESTRANGEIRA E MEDICAMENTOS SEM REGISTRO DA ANVISA. CONDENAÇÃO PELO DELITO PREVISTO NO ART. 273, § 1º-B, I, CP. UTILIZAÇÃO PELAS INSTÂNCIAS DE ORIGEM DAS PENAS PREVISTAS NO ART. 272 DO CP. PRECEITO SECUNDÁRIO MAIS BENÉFICO. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DA MINORANTE E DE MAJORANTES PREVISTAS NA LEI DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO. 1. No julgamento da Arguição de Inconstitucionalidade no HC 239.363/PR, a Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça declarou a inconstitucionalidade do preceito secundário do art 273, § 1º-B do Código Penal, autorizando a aplicação analógica das penas previstas para o crime de tráfico de drogas, contudo ainda prevalece nesta Turma a compreensão de inaplicabilidade das causas de aumento e redução de pena do tráfico ao delito do art. 273, § 1º-B do CP. 3. Mesmo admitindo-se a minorante, então incidiriam também as majorantes, a crime que tem pena do tipo básico até maior, tendo em vista que o preceito secundário disposto no art. 272 do CP prevê pena em abstrato de 4 a 8 anos de reclusão, inferior à prevista no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, de 5 a 15 anos, razão pela qual não se verifica que a aplicação da Lei de Drogas seja mais benéfica ao recorrente. 4. Maiores considerações sobre o preenchimento das condições para a aplicação da minorante prevista no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 demandariam o reexame fático-probatório, vedado pela súmula n. 7/STJ. 5. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no Resp: 1888831 SP 2020/0201012-0, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 15/12/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/12/2020) Ainda:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FALSIFICAÇÃO, CORRUPÇÃO, ADULTERAÇÃO OU ALTERAÇÃO DE PRODUTO DESTINADO A FINS TERAPÊUTICOS OU MEDICINAIS. VENDA DE 4 (QUATRO) COMPRIMIDOS CYTOTEC POR PROPRIETÁRIO DE FARMÁCIA (ART. 273, § 1-B, INCS. I E V, DO CP). INCONSTITUCIONALIDADE DO PRECEITO SECUNDÁRIO PREVISTO NO ART. 273, § 1º-B, V, DO CÓDIGO PENAL DECLARADA NO JULGAMENTO DA AI NO HC N. 239.363/PR (ART. 273, § 1-B, V, DO CÓDIGO PENAL). DESPROPORCIONALIDADE DOS DEMAIS INCISOS. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/06. PRECEDENTES. 1. No julgamento da AI no HC n. 239.363/PR, o Relator afirmou ser necessário conferir à decisão caráter manipulativo de efeitos substitutivos, a fim de dar à norma interpretação conforme a Constituição Federal, promovendo, assim, seu ajuste principiológico. Declarou-se a inconstitucionalidade do preceito secundário (art. 273, § 1-B, V, do CP), substituindo-o pela pena prevista no art. 33 da Lei de Drogas, "com possibilidade até de incidência do respectivo § 4º". 2. Não obstante a AI no HC n. 239.363/PR tenha se referido apenas ao inc. V do art. 273, § 1º-B, do Código Penal, os demais incisos do referido dispositivo legal padecem da mesma desproporcionalidade entre a conduta e a pena. 3. No caso, o agravante, no interior da farmácia de sua propriedade, vendeu para um cliente o medicamento abortivo Cytotec (4 comprimidos), sem o devido registro no órgão de vigilância sanitária e, por conseguinte, de procedência ignorada, restando condenado por infração ao art. 273, § 1º-B, incs. I e V, do Código Penal. 4. Conforme afirmei à oportunidade do julgamento do HC n. 274098/MG, em 9/5/2017,

entendo não haver óbice à aplicação do referido precedente da Corte Especial, no caso dos autos, afastando-se, assim, o preceito secundário do art. 273, § 1º-B, do Código Penal, com a incidência, inclusive, da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06. 5. Agravo regimental provido. (STJ - AgRg no Resp: 1602268 DF 2016/0144371-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 19/09/2017, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/09/2017) Deste modo, a sentença passará a conter a seguinte redação, a partir da dosimetria penal, adotando-se, para tanto, a aplicação analógica das penas previstas para o crime de tráfico de drogas:

Dosimetria.

1ª Fase da Dosimetria Penal. Na primeira fase da dosimetria, não vislumbro circunstâncias judiciais desfavoráveis. Fixo a pena-base em 05 anos de reclusão e 500 dias-multa.

2ª Fase da Dosimetria Penal. Na segunda fase da dosimetria, inexistem circunstâncias legais atenuantes. Presente a agravante do artigo 61, inciso II, "j", do Código Penal, aumento a pena em 1/6, fixando a pena-intermediária em 05 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa.

3ª Fase da Dosimetria Penal. Na terceira fase, inexistem causas de aumento ou de diminuição de pena, de modo que fixo a pena em definitivo em 05 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa. Entendo não ser o caso de aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, notadamente em razão da expressiva quantidade de medicamentos apreendidos (336 comprimidos), que eram mantidos em depósito e guardados para a venda em um ponto comercial, o que demonstra profissionalismo e dedicação à criminalidade. Fixo a pena em definitivo em 05 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa.

O regime inicial deve ser o fechado, em observância ao disposto no artigo 2º, §2º, inciso VII-B, da Lei nº 8.072/1990, o qual estabelece o regime fechado para os crimes hediondos e os equiparados, bem como por ser o único apto a atender o binômio prevenção-repressão, dada que as circunstâncias judiciais plenamente desfavoráveis a ré.

Em razão da pena aplicada, não são cabíveis os benefícios penais e processuais penais.

DISPOSITIVO.

Posto isso, julgo PROCEDENTE o pedido formulado na denúncia, para CONDENAR a ré SHERLINE RICHARD como incurso nas sanções do artigo 273, §1º-B, combinado com o artigo 61, inciso II, "j", ambos do Código Penal à pena de 05 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 583 dias-multa, cada qual no mínimo legal.

A ré não tem o direito de apelar em liberdade. Primeiro, por permaneceu presa durante o processo, de modo que seria um contrassenso soltá-lo após a condenação. Segundo, porque permanecem presentes os requisitos da prisão preventiva, notadamente no que diz respeito à necessidade de se assegurar a ordem pública.

Custas pela ré, na forma da Lei estadual nº 11.608/2003, artigo 4º. §9º, a, (100 UFESPs), observado o artigo 12 da Lei nº 1.060/50, em caso de defesa pela Defensoria Pública. Após o trânsito em julgado, nos termos do Provimento nº 33/2012 da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de São Paulo, lance-se a condenação no Sistema Informatizado Oficial existente na serventia, comunicando-se ao Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt (IIRGD). Oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral para o cumprimento do artigo 15, inciso III, da Constituição Federal. Expeça-se guia de execução definitiva, remetendo-se ao Juízo competente.

P.R.I.C.

São Paulo, 02 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA